

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 共謀共同正犯において、「共謀」は、罪となるべき事実にはかならないから、訴因においてその存在を明示することを要し、これを認定するためには厳格な証明によらなければならない。
- イ. 殺人罪の共同正犯において、実行行為者が誰であるかは、罪となるべき事実の特定に不可欠とはいえないものの、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項であるから、検察官は、訴因に実行行為者を明示しなければならない。
- ウ. 検察官において、共謀共同正犯の存在に言及することなく、被告人が1人で原動機付自転車を窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合に、裁判所が、証拠上、他に実行行為を行っていない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たときは、被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされたと認めるときであっても、検察官に対し、訴因の変更を積極的に促し、又はこれを命じなければならない。
- エ. 被告人が共謀共同正犯として起訴された事件において、検察官が主張せず、被告人側も防御活動を行っていない日時における謀議について、裁判所が、争点としてこれを顕在化させる措置を採ることなく、その日時における謀議への被告人の関与を認定したとしても、取り調べた証拠から認定したものである限り、被告人に不意打ちを与え、その防御権を不当に侵害するものとして違法となることはない。
- オ. 被告人及びAを共同正犯とする殺人被告事件において、実行行為者が誰であるかが争点となり、審理を尽くしても実行行為者を特定するに至らなかった場合には、裁判所は、実行行為者につき、「被告人若しくはA又はその両名」と認定し、その旨を罪となるべき事実として判示することが、許されることがある。

1. ア イ 2. イ ウ 3. ウ エ 4. エ オ 5. ア オ

ア 正しい

訴因とは、検察官が裁判所に対して審判を求める「罪となるべき事実」をいうところ、最大判昭33.5.28（百選A44事件）は、「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない」としている。よって、「共謀」は、訴因に含まれるので、訴因において、その存在を明示しなければならない（256条3項参照）。なお、実務においては、起訴状において単に「共謀の上」とのみ記載されるのが通例である。

イ 誤っている

最決平13.4.11（百選46事件）は、殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否が争点となった事例において、「殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえない」としており、殺人罪の共同正犯において実行行為者が誰であるかは、罪となる事実の特定に不可欠とはいえないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として審判対象の画定という見地からは、共同正犯内部で実行行為者が確定できない場合でも、共謀共同正犯の法理において共謀関与者の全部又は一部が犯罪を実行すれば、共謀関与者の間で刑事責任の成否に差異はないということを挙げている。よって、本記述前段は正しい。

さらに、判例は、被告人の防御権の確保の観点から実行行為者を訴因で明示する必要があるかにつき、「実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項である」と評価したものの、「当該訴因の成否について争いがある場合等においては、争点の明確化などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましい」とするにとどめ、「明示しなければならない」とはしていない。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、訴因の明示の第一次的機能は審判対象の画定であるということを挙げている。よって、本記述後段は誤っている。

ウ 誤っている

最決平21.7.21（重判平21刑訴6事件）は、検察官が被告人の単独犯として起訴した連続的な窃盗事件において、被告人がすべての実行行為を行ったことが明らかであり、かつ、証拠中に共謀共同正犯者の存在を認定できる証拠が存在したという事案において、「検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは、他に共謀共同正犯者が存在するとしてもその犯罪の成否は左右されないから、裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される」としており、裁判所は、検察官に対し、訴因の変更を積極的に促し、又はこれを命じなければならないとはしていない。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされる場合において、他の共謀共同正犯者が存在するときに単独犯、共同正犯のいずれの訴因で起訴するかはその訴追裁量の問題であること、②一般に、訴追裁量権は合理的に行使されなければならないが、単独犯と共同正犯の場合、告訴・告発を潜脱するなどの問題はなく、その訴追裁量権の行使が合理性を欠くと評価される事態は想定し難いことなどを挙げている。

エ 誤っている

最判昭58.12.13（百選A26事件）は、謀議の日時が争点となった事案において、原審が認定した「12日夜……謀議が行われたという事実は、……検察官が特段の主張・立証を行わず、その結果として被告人・弁護人も何らの防禦活動を行っていない……。したがって、……原審が、第一審判決の認めた13日夜の第一次協議の存在に疑問をもち、右協議が現実には12日夜に行われたとの事実を認定しようとするのであれば、少なくとも、12日夜の謀議の存否の点を控訴審における争点として顕在化させたうえで十分の審理を遂げる必要があると解されるのであつて、このような措置をとることなく、13日夜の第一次協議に関する被告人のアリバイの成立を認めながら、率然として、右第一次協議の日を12日夜であると認めてこれに対する被告人の関与を肯定した原審の訴訟手続は、本件事案の性質、審理の経過等にかんがみると、被告人に対し不意打ちを与え、その防禦権を不当に侵害するものであつて違法である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、争点として顕在化させた上で十分な審理を遂げさせることにより、被告人の防禦権を保障しつつ円滑な訴訟進行を図ることができるという点を挙げている。

オ 正しい

最決平13.4.11（百選46事件）は、殺人罪の共同正犯についての第一審の判示について、「実行行為者が『A又は被告人あるいはその両名』という択一的なものにとどまるが、……罪となるべき事実の判示として不十分とはいえない」としている。その理由として、判例は、「その事件が被告人とAの2名の共謀による犯行であるというのであるから、この程度の判示であっても、殺人罪の構成要件に該当すべき具体的事実を、それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにしている」ということを挙げている。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢5となる。

